

1500252-93.2020.8.26.0626

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Comarca: Ilhabela

Foro: Foro de Ilhabela

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 19/09/2022

... pelo afastamento da hediondez do delito de tráfico privilegiado (artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADO POR TRÁFICO PRIVILEGIADO E POR TRÁFICO PREVISTO NO CAPUT DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006.

REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA AFASTADA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ilhabela

Foro de Ilhabela

Vara Única

Rua Benedito dos Anjos Sampaio, 29, Ilhabela-SP - cep 11630-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500252-93.2020.8.26.0626 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500252-93.2020.8.26.0626

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2156174/2020 - DEL.POL.ILHABELA, 12118004 - DEL.POL.ILHABELA, 1236/20/302 -

DEL.POL.ILHABELA, 1236/2020 - DEL.POL.ILHABELA, 2156174 - DEL.POL.ILHABELA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATHAN SAGRILO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Vistos.

JONATHAN SAGRILO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/2006, porque, na data e local descritos na denúncia, trazia consigo e tinha guardado, para o fim de consumo de terceiros, substância entorpecente (10,8 gramas de cocaína) que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

A denúncia de fls. 91/92 foi recebida em 08 de julho de 2020 (fls. 142/145).

O réu foi citado, apresentando defesa (fls. 121/128).

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas de acusação e defesa arroladas, e o réu foi interrogado (fls. 209/210).

Em seus memoriais (fls. 269/278), o Doutor Promotor de Justiça, entendendo que estão suficientemente provadas a autoria e a materialidade do delito requereu fosse a ação penal julgada procedente, com a conseqüente condenação do réu.

O Doutor Defensor do réu (fls. 26/305), requereu o réu a absolvição por falta de provas, a desclassificação para o delito de porte de entorpecentes, ou a aplicação do regime aberto.

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes se encontra comprovada pelos laudos de fls. 180/182 e 244/265.

É notório o perigo à incolumidade pública causado pela droga conhecida como cocaína, de alto poder viciante e que causa dependência física e psíquica, demonstrando estar plenamente caracterizada a prática delitiva.

De acordo com a doutrina:

"É tão grave a nocividade dessa droga que, mesmo depois da cura pela desintoxicação, o viciado não se recupera das lesões mais graves do sistema nervoso. Tem estados depressivos e de angústia, alucinações visuais e tácteis, delírios de perseguição e complexo de culpa. Envelhece muito precocemente, e a morte é quase sempre por perturbações cardíacas" (DE FRANÇA, GENIVAL VELOSO. Medicina Legal. 7ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004, p.308).

A esse respeito, a matéria publicada no conceituado jornal "Folha de São Paulo"; em 30 de dezembro de 1994:

"Cocaína é maior causa de infarto em jovens

A cocaína é responsável por quase todos os infartos do miocárdio em jovens com menos de 30 anos. A constatação é da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) que lança na próxima semana uma campanha nacional de informação.

O objetivo é esclarecer as pessoas sobre as doenças do coração e o que se deve fazer para evitá-las. Entre os jovens, o uso da cocaína é o que mais preocupa a SBC.

"Eles precisam saber que a cocaína tem efeitos mortais no organismo", diz Claudio Buarque Benchimol, 47, secretário-geral da SBC. "Quase todos os jovens que chegam com infarto nos hospitais fizeram uso de cocaína", afirma.

É o que acontece no Instituto do Coração (Incor) do Hospital das Clínicas, umas das mais importantes portas de entrada de vítimas de infarto em São Paulo.

O cardiologista Marcello Barduco, do pronto-socorro do Incor, confirma que entre os jovens a causa do infarto está quase sempre associada ao uso de cocaína.

O hospital registra uma média de um a três casos de infartos em jovens por mês. A cada 24 horas, o Incor recebe uma média de cinco vítimas de infarto, idosos na grande maioria.

Não há estudos sobre os riscos nem estatísticas sobre casos de infarto por droga entre jovens. De acordo com Benchimol, o número de mortes do coração provocado por cocaína pode estar subnotificado por interferência da família. Ou mesmo pela dificuldade em se apontar a droga como causa.

De todo modo, o número de jovens que morrem por infarto é pequeno. Segundo dados da Fundação Seade, apenas 33 jovens entre 15 e 29 anos morreram de infarto do

miocárdio na cidade de São Paulo no ano passado. Para se ter uma idéia, nesse mesmo período, 2.298 jovens dessa faixa de idade foram assassinados com armas de fogo e outras armas. Outros 561 morreram no trânsito.

A preocupação da SBC é com o aumento do uso da cocaína registrado nos últimos anos. "O número de usuários dessa droga vem aumentando no mundo todo", diz Benchimol.

Pesquisa feita entre estudantes de 1º e 2º grau de dez capitais brasileiras mostra que 1,2% deles já experimentou cocaína. Cinco anos atrás, apenas 0,7% dos estudantes tinham usado a droga uma vez. A pesquisa foi feita pelo Cebrid, Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas.

O perigo da cocaína é apenas um dos itens da campanha da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Os médicos pretendem informar em linguagem simples como se iniciam as doenças do coração e o que pode agravá-las ou fazer com que regredam.

A hipertensão arterial e o fumo, por exemplo, são fatores de risco para um infarto. Alimentação correta, pouco estresse e exercícios físicos ajudam a manter o coração mais saudável."

E ainda:

"A quantidade necessária para provocar uma overdose varia de uma pessoa para outra, e a dose fatal vai de 0,2 a 1,5 grama de cocaína pura. A possibilidade de overdose, entretanto, é maior quando a droga é injetada diretamente na corrente sanguínea. O efeito da cocaína pode levar a um aumento de excitabilidade, ansiedade, elevação da pressão sanguínea, náusea e até mesmo alucinações.

(...)

A cocaína é a droga que mais rapidamente devasta o usuário. Bastam alguns meses ou mesmo semanas para que ela cause um emagrecimento profundo, insônia, sangramento do nariz e coriza persistente, lesão da mucosa nasal e tecidos nasais, podendo inclusive causar perfuração do septo (12). Doses elevadas consumidas regularmente também causam palidez, suor frio, desmaios, convulsões e parada respiratória".

(S.H. Cardoso e R.M.E. Sabbatini; Revista Cérebro & Mente 3(8), jan/mar 1999).

A autoria, relativo ao tráfico, é indubitosa.

O réu foi preso em flagrante, que segundo Rafael Magalhães, apud Tourinho Filho "é a certeza visual do crime". A expressão também é usada na doutrina clássica por Tostes Malta, na obra *Do Flagrante Delito*, 1933, p. 25. De acordo com Hélio Tornaghi, prender em flagrante é capturar alguém no momento em que comete um crime. Ainda segundo o ilustre autor:

"Nunca é demais lembrar que a flagrância talvez seja a prova mais eloquente do crime e da respectiva autoria" (Curso de Processo Penal, 5ª ed., II/49).

De acordo com a jurisprudência, a prisão em flagrante implica indícios de autoria em desfavor do agente. Nesse sentido:

Furto - Tentativa - Suficiência probatória. Os elementos probantes amealhados nestes autos foram concludentes quanto à efetiva participação do recorrente na tentativa de furto, principalmente se levado for em consideração o fato de sua prisão em flagrante delito, transmutada na certeza visual do crime, sem esquecer-se, da robusta prova oral colhida, durante a instrução criminal. (Apelação nº 990.10.149887-1, Voto 20.894, da 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: WILSON BARREIRA, Data 02/09/2010)

PRISÃO EM FLAGRANTE - Prova - Certeza visual do delito que gera indícios de autoria em desfavor do agente - Entendimento:59(b) - A prisão em flagrante, por ser a certeza visual do delito, gera indícios de autoria em desfavor do agente. (Habeas Corpus nº 374.018/3, Julgado em 29/01/2.001, 12ª Câmara, Relator: Amador Pedroso (Presidente), RJTACRIM 52/205)

ROUBO MAJORADO. Apelação Criminal Ministerial. Condenação. Possibilidade. Vítima ouvida somente na fase extrajudicial. Irrelevância. Certeza visual do crime. Autoria comprovada pela prova oral. Recurso provido. (Apelação nº 0090593-

47.2008.8.26.0050, da m 2ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: EDUARDO ABDALLA, Data: 09/08/2013)

Tanto na fase de investigação, quanto em Juízo, os policiais militares informaram que já conheciam o réu de outras abordagens e denúncias de tráfico, nas quais constava que o réu atuava para terceiro (Becan). Relativo aos fatos, informaram que se encontravam em patrulhamento, quando visualizaram o réu sentado perto de um árvore, em frente a um estacionamento público de uso de um bar e das residências, sendo que este, quando avistou a viatura, demonstrou certo nervosismo, optando pela abordagem. Em revista pessoal foram localizadas doze porções de substância entorpecente, aparentando tratar-se de cocaína, em sua cueca, além de uma quantia em dinheiro e um celular, em seus bolsos. Considerando a proximidade de sua residência, conversaram com a genitora a qual indicou que ele residia em um cômodo anexo da casa, tendo autorizado a entrada e acompanhado a busca, onde foi localizado, dentro do travesseiro cerca de três mil reais, e seis comprovantes de depósito em nome de Cesar. Narraram que o réu desbloqueou o celular, onde foram verificados outros comprovantes de depósito, além de conversas com o traficante. Indagado o réu confirmou que a droga seria para a venda.

São irrelevantes as pequenas contradições da prova testemunhal, em razão das próprias imperfeições humanas, máxime quando as testemunhas concordam sobre pontos e circunstâncias essenciais. Segundo Borges da Rosa:

“Como dizem BINET, STERN, VARENDONCK, GORPHE, BANCELS e outros, os erros são elementos constantes na prova testemunhal; a testemunha não sujeita a erros não existe, porque o depoimento, o testemunho, é uma reprodução pessoal e lacunar da realidade. As divergências e contradições entre os depoimentos de duas ou mais testemunhas são, portanto, naturais; o que não é natural é a conformidade dos mesmos, que faz supor a identidade de inspiração, o concerto prévio, o eumdem premeditatum sermonem, de que fala FLAMARINO MALATESTA, na sua Lógica das Provas” (Comentários ao Código de Processo Penal, 3ª Ed., RT, 1982, pág. 322).

Assim sendo, pequenas divergências nos aspectos secundários, porém com coincidência nos essenciais, entre os relatos das vítimas e testemunhas não lhes retiram o valor probatório. Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

Roubo simples tentado e ameaça – art. 157, caput, c.c. art. 14, II e art. 147, todos do CP Absolvição por insuficiência de provas Impossibilidade – Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Robusto conjunto probatório (...) – Aliás, ao contrário do que alega a defesa, apesar de haver divergências entre os depoimentos das testemunhas, isto em nada altera a segurança com a qual elas narraram os crimes, tratando-se de pequenas discrepâncias normais que decorrem naturalmente da narrativa pessoal de cada depoente – (...). (Apelação Criminal nº 1509240-70.2019.8.26.0228, da 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: FREITAS FILHO, Data: 29 de janeiro de 2020)

APELAÇÃO – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa – Preliminar – Nulidade da sentença – Ausência de enfrentamento das alegações defensivas e falsidade dos depoimentos judiciais dos policiais militares – Inocorrência – Decisão motivada – Desnecessidade de menção pormenorizada sobre cada um dos argumentos apresentados – Pequenas divergências nos depoimentos das testemunhas não são suficientes para macular a prova colhida – Policiais que não teriam qualquer motivo para incriminar falsamente os acusados – (...) – Sentença mantida – Recurso não provido (Apelação nº 1501078-10.2017.8.26.0567, da 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: SALLES ABREU, Data: 011 de agosto de 2018)

APELAÇÃO – tráfico de drogas qualificado. Apelante que nega o delito. Testemunha de defesa sem credibilidade por contradições e inconsistência fática de sua fala, inclusive com determinação de processo para averiguar o falso testemunho. Testemunhas de acusação coesas quanto ao essencial. Pequeno desvio é derivado da condição de abordagem. Policial é testemunha como qualquer outra pessoa e

impugnação a ele deve ser específica, determinada e não genérica pela origem. (...). (TJSP; Apelação Criminal 1500462-48.2018.8.26.0228; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavaleiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 14ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/04/2020; Data de Registro: 20/04/2020)

Pequenas divergências entre os relatos das testemunhas - Irrelevância - Validade. 63 (b) - As pequenas contradições na prova decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas, em geral, pelas condições em que a prova é realizada. Assim, de se desconfiar do testemunho demasiado perfeito, sendo, sim, importante, verificar se, embora discrepantes em detalhes mínimos, concordam os depoimentos nos pontos essenciais, quanto às circunstâncias decisivas do fato. RJDTACRIM VOLUME 6 PÁG.78 ABRIL/JUNHO/90 RELATOR:-JOSÉ HABICE.

Inclusive, julgando Apelação Criminal oriunda deste juízo, assim decidiu a 14ª Câmara do 7º Grupo da Seção Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Ressalte-se que, eventuais discrepâncias entre os depoimentos não geram insegurança acerca dos fatos, pois oriundas das imperfeições do psiquismo humano, agravadas, em geral, pelas condições em que a prova é realizada, sendo, sim, importante, verificar se, embora divergentes em detalhes mínimos, concordam os testemunhos nos pontos essenciais, quanto às circunstâncias mais decisivas dos fatos" (Apelação Criminal nº 00976517.3/3-0000-000, Rel. DES. FERNANDO MATALLO, 24.05.2007).

Em que pesem as alegações da defesa acerca da entrada ilegal, a preliminar suscitada deve ser afastada.

Com efeito, já é pacífico na jurisprudência a possibilidade do policial militar ou guarda municipal realizar a prisão, porque nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer do povo pode realizar prisão em flagrante. Além disso, o direito à inviolabilidade do domicílio possui exceção na própria constituição, no caso de flagrante delito.

Tendo em vista que o delito de tráfico de entorpecentes é delito permanente, cuja consumação se protraí no tempo, não há nenhuma ilegalidade na atitude dos policiais.

À respeito da natureza permanente do delito, ensina Júlio Fabbrini Mirabete:

"Dispõe o artigo 303 que, nas infrações, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência, o que, na verdade, é despidiendo, já que, nessa espécie de ilícito, a consumação se prolonga no tempo, dependendo da vontade do agente, como ocorre nos crimes de seqüestro (art. 148, do CP), de extorsão mediante seqüestro (art.

149, do CP), nos crimes cuja conduta é 'guardar consigo \ 'ter em depósito', 'transportar' etc. Nessas hipóteses o crime está sendo cometido durante o tempo da consumação, havendo, pois, caso típico de flagrância. O dispositivo, porém, evita qualquer interpretação em contrário, cumprindo ressaltar que é ele repetido no Código de Processo Penal italiano de 1988 (art. 328,2). Não se contesta a situação de flagrância nessas hipóteses, inclusive quanto ao crime de quadrilha, em ação de transporte de coisas subtraídas, de receptação dolosa por ocultação, de depósito de substância entorpecente etc.

Evidentemente, tratando-se de prisão em flagrante, mesmo nas hipóteses em que se deva invadir casa alheia, não se exige mandado judicial (g.n. -Processo Penal - 3a ed. - Ed. Atlas - 1994 - pág. 360).

Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência:

APELAÇÃO. Direito de recorrer em liberdade. Perda superveniente do objeto. Prova ilícita. Inexistência. Situação flagrancial que autoriza o ingresso na residência

independentemente de ordem judicial. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Tráfico ilícito de entorpecentes. Insuficiência de provas. Inocorrência. Circunstâncias que evidenciam que a droga se destinava à mercancia. Palavra dos agentes policiais que merece crédito. Desclassificação da conduta. Impossibilidade. Pena privativa de liberdade. Majoração da pena-base de rigor. Inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. Pena intermediária. Atenuante genérica da confissão. Cabimento. Inaplicabilidade do redutor do art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas. Regime inicial de cumprimento da pena. Regime fechado que se mostra mais adequado ante as circunstâncias do caso concreto, a despeito do teor do art. 387, §2º, do CPP. Pena restritiva de direitos. Não cabimento. Manutenção da prisão. Persistência dos motivos ensejadores da prisão preventiva agregada à possibilidade de execução provisória da pena após a prolação do acórdão condenatório. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 0000004-65.2015.8.26.0631; Relator (a): Luiz Fernando Vaggione; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Amparo - 1ª Vara; Data do Julgamento: 21/11/2016; Data de Registro: 29/11/2016)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LICITUDE DA PROVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protraí no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosas, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal. 2. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, reafirmou o referido entendimento, com o alerta de que para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 3. No caso em exame, a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial evidencia-se no fato de que, após chegada ao local para averiguação de "denúncia anônima" recebida acerca da chegada de um carregamento de drogas na residência, o corréu ALEX percebeu a presença da guarnição e correu para dentro do imóvel, momento em que os policiais decidiram ingressar na residência e flagraram os corréus VILSON e ARIZON descarregando tabletes de pasta-base de cocaína de uma Kombi semidesmontada, tendo o paciente e o corréu OSVALDO sido detidos no interior do domicílio. Realizada as buscas pessoais, veiculares e as demais diligências, a atividade policial logrou em apreender 107 tabletes de pasta-base de cocaína, pesando 95,245Kg. De sorte que eram fundadas as razões para a atuação policial. Desse modo, na presença de elementos suficientes a autorizar a medida estatal, não há como acolher a alegada ilicitude da prova para absolver o paciente pela prática do delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 569.437/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 01/06/2020)

Recurso de habeas corpus. Prisão em flagrante. Guarda municipal. Apreensão de coisas. Legalidade. Delito permanente. - "A guarda municipal, a teor do dispositivo, § 8º do artigo 144 da CF, tem como tarefa precípua a proteção do patrimônio do Município, limitação que não exclui nem retira de seus integrantes a condição de agentes da autoridade, legitimados, dentro do princípio de autodefesa da sociedade, a fazer cessar eventual prática criminosas, prendendo quem se encontra em flagrante delito, como de resto facultado a qualquer do povo pela norma do art. 301 do CPP. Nestas circunstâncias, se a lei autoriza a prisão em flagrante, evidentemente que faculta - também - a apreensão de coisas, objeto do crime. Apenas o auto de prisão em flagrante e o termo de apreensão serão lavrados pela autoridade policial. Arguição de nulidade rejeitada, visto que os acusados, quando detidos, estavam em situação de flagrância, na prática do crime previsto no art. 12 da Lei 6.368/76 - modalidade guardar substância entorpecente" (STJ - 6ª T. - RHC 7.916- Rel. Fernando Gonçalves - DJU 09.11.1998; Revista Jurídica 255/126; JSTJ e TRF-LEX 115/303).

“Não há ilegalidade na prisão, vez que realizada em flagrante delito, nos termos do artigo 302, do Código de Processo Penal, por guardas municipais, ainda que não possuam a função de preservar a segurança pública (destinou-se-lhes apenas a proteção de bens, serviços e instalações municipais artigo 144, § 8º, da Constituição Federal). Ademais, como é cediço, qualquer do povo poderá render quem quer que seja encontrado em flagrante delito (artigo 301, do Código de Processo Penal), constituindo notório contrassenso admitir que guardas municipais não possam proceder da mesma maneira legal.(TJSP – 14ª Câmara, Apelação nº 0017308-46.2010.8.26.0019, Relator Des. Marco de Lorenzi, j. 01.03.2012)

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA MUNICIPAL. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA. ART. 301 DO CPP. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão em flagrante efetuada pela Guarda Municipal, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais (art. 144, § 8º, da CF), constitui ato legal, em proteção à segurança social. 2. Se a qualquer do povo é permitido prender quem quer que esteja em flagrante delito, não há falar em proibição ao guarda municipal de proceder à prisão. 3. Eventual irregularidade praticada na fase préprocessual não tem o condão de inquinar de nulidade a ação penal, se observadas as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, restando, portanto, legítima a sentença condenatória. 4. Ordem denegada. (STJ, 5ª Turma, HC 129932/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 15.12.2009).

A jurisprudência é demasiada sólida acerca da natureza permanente dos delitos, especificamente o delito de tráfico de drogas, caso dos autos, existindo circunstância que justificam a incursão policial no imóvel, sendo desnecessário mandado de busca.

No mais, a presente demanda originou-se de encontro fortuito durante a realização de diligência policial de rotina. A apreensão da droga na área externa da residência, e a indicação de endereço próximo, somado com autorização de acesso, comprova a legalidade dos atos perpetrados.

Assim, não procedem as alegações da defesa quanto à divergência/imprestabilidade dos depoimentos dos policiais. O depoimento dos policiais tem o mesmo valor que o de qualquer outra testemunha, ainda mais quando a mera alegação de “não comprovação da autorização de entrada” vem desacompanhada do menor indício de prova, como no caso dos autos. O entendimento jurisprudencial não é diverso:

Tráfico de entorpecentes – Agente surpreendido trazendo consigo, para fins de tráfico, 21,5 gramas de cocaína, em pó – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. Tráfico de entorpecentes – Dolo de traficar – Desclassificação para porte de entorpecentes (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – Descabimento Provado o dolo genérico de traficar, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não cabe a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06, se for observado que as demais circunstâncias que cercaram a prisão do acusado dão conta da caracterização do tráfico de entorpecentes. (TJSP; Apelação Criminal 0003382-85.2013.8.26.0538; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santa Cruz das Palmeiras - Vara Única; Data do Julgamento: 13/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HC PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão combatido concluiu que "os dados acidentais e os contornos acessórios do fato justificam o juízo condenatório, pois firmada a evidência de não corresponder a ação do réu, por qualquer argumento, ao uso de entorpecente. Assim, entendo que não deve ser aplicada a desclassificação ao caso em epígrafe, para que não seja violado aquilo que se conhece por razoável, na medida em que, na espécie, não se cogita do imponderável sobre a existência do fato e da autoria, mas, ao contrário, se denota, de forma efetiva, que a conduta do réu deve ser classificada como inclusa no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006". Dessa forma, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela desclassificação da conduta do agravante para uso de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 2. Esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016). 3. (...). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1686847/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão combatido concluiu que "diante das circunstâncias da prisão, a quantidade do material, a forma de seu acondicionamento, o local onde foi apreendido, a conduta do acusado e os depoimentos contundentes dos policiais, levam à conclusão inequívoca da prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06" (e-STJ, fl. 401). Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição ou desclassificação da conduta do agravante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento vedado na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ. 2. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020)

PROVA CRIMINAL - Testemunhal - Hipótese de tóxico - Depoimento prestado por policial - Admissibilidade - Relato que não deixa dúvida alguma do encontro de maconha em poder do agente - Condenação mantida O agente da polícia serve como testemunha, tal qual qualquer outra pessoa, até porque ele é auxiliar da Justiça criminal e não é de supor-se que se transforme em parte, que compareça a juízo para perseguir sistematicamente pessoas inocentes, para as quais criam crimes inexistentes. (Relator: Djalma Lofrano - Apelação Criminal n. 159.299-3 - Botucatu - 18.08.94)

Assim, diversamente do sustentado, nenhum abuso ocorreu na diligência policial, desencadeada por patrulhamento de rotina em região conhecida pelo intenso tráfico de drogas. Tratando-se "de crime permanente, a ensejar sempre prisão em flagrante, não há que se questionar sobre a preexistência, nulidade ou descumprimento de

mandado judicial de busca e apreensão, porque a inviolabilidade domiciliar é princípio que não se compadece, em termos infracionais, com o desvio de finalidade da função da própria casa, conforme se infere do disposto no art. 5º, XI, da Constituição Federal” (JCAT 75/590).

A forma de acondicionamento de tóxico apreendida, além da quantia em dinheiro, evidencia a destinação de tráfico.

Ainda que se considere pequena a quantidade que o réu portava, já ficou patente que os “patrões” do tráfico costumam utilizar-se de pequenos traficantes para a venda. Confira-se à respeito, a matéria do Jornal “O Liberal” de Americana, no dia 21 de junho de 2009:

MICROTRAFICANTES VIRAM O PRINCIPAL FOCO

DA POLÍCIA - Os microtraficantes, como são chamadas pela polícia as pessoas que vendem pequenas quantidades de drogas, são o novo foco dos investigadores da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes). “Esse tipo de traficante é como erva daninha. Quanto mais se prende, mais surge. Por isso temos de combatê-los. Queremos chegar no 'patrão' que está no topo e na base da pirâmide do tráfico”, disse o delegado Marco Antonio Pozzetti, titular da DISE. Na semana passada, cinco microtraficantes foram presos. Esta forma de comércio foi criada pelos 'patrões' do tráfico para não sofrerem grandes baixas quando a polícia age. Cada micro fica no ponto de venda, conhecido como 'biqueira', com no máximo 20 unidades de entorpecentes (pedrinhas de crack, papelotes de cocaína e pequenos embrulhos de maconha). Eles são abastecidos pelos 'gatos' como os 'patrões' identificam os distribuidores.

“Os investigadores estão saindo às ruas à procura dos microtraficantes. Na quinta-feira, por exemplo, prendemos um que vendia drogas sentado em um sofá na calçada de sua casa, no Jardim Guanabara. Com ele nós encontramos seis pedrinhas de crack, dois pedacinhos de maconha e mais R\$ 30,00. É o exemplo do microtraficante. Ele estava com uma quantidade reduzida”. Disse o delegado da DISE. “O surgimento dos microtraficantes é uma forma criada pelos 'patrões' do tráfico para evitar grandes tombos. Prendemos muitas pessoas e a quantidade de entorpecente apreendida é pequena. Assim, a 'biqueira' não sofre prejuízo”, contou o delegado.

Uso próprio

As pessoas que são presas também tentam se beneficiar do artifício da pequena quantidade. Eles procuram provar, na Justiça, que o entorpecente pe para uso. Assim, tentam 'quebrar' a prisão de tráfico para uso de entorpecente. “A maioria alega que estava com aqueles papelotes ou pedrinhas par consumo próprio”, afirmou um dos investigadores da DISE. Pozetti instruiu os policiais a agirem nas duas pontas da pirâmide do tráfico. “Os micros estão na base e fazendo prisões. Nós conseguimos enfraquecer e até chegar aos donos do comércio”, comentou. Os policiais aproveitam as prisões para fazer um mapeamento do esquema do tráfico em Americana. “Nós já sabemos, por exemplo, quem são os responsáveis pelas principais biqueiras. São informações que surgem com as prisões desses microtraficantes”, disse o policial. O perfil do vendedor de pequenas quantidades de droga é diversificado, conforme avaliam os policiais da DISE. São adolescentes, jovens e até crianças. Um numero cada vez maior de mulheres tem atuado nas 'biqueirinhas' como costuma chamar o delegado. (...) Em americana, as prisões aconteceram no Jardim Guanabara, Vila Bela, Parque da Liberdade, São Roque, São Jerônimo e na Praia Azul. (...) “O Jardim Guanabara, em Americana, por exemplo, aparece como uma das áreas de grande concentração de pequenos pontos de venda de drogas e vamos intensificar nosso trabalho” afirmou Pozetti.

A testemunha Douglas, irmão do réu, disse ter conhecimento que seu irmão é usuário de drogas, mas nunca escutou que ele vendia. Informou que não presenciou os fatos, e que o quarto do irmão e na casa da mãe. E que o estacionamento e particular para os moradores das casas.

Ainda, a testemunha Iracema, genitora do réu, declarou que suspeitava que seu filho era usuário de drogas. Disse, ainda, que para chegar ao imóvel tem que passar pelo portão do estacionamento, o qual é particular, e um segundo portão, depois chega na entrada da sua área. Os policiais chegaram no portão de sua casa, anunciaram a prisão de seu filho, e invadiram sua casa. Informou que para chegar chegar no quarto do réu tem que passar por sua lavanderia. Por fim, acompanhou a vistoria no quarto, mas não viu localizarem o dinheiro.

Em que pesem as declarações da testemunha de defesa, ausente de compromisso, não podem ser consideradas para isentar o réu do delito.

Verifica-se que, na divergência entre os depoimentos das testemunhas, deve se dar preferência para o depoimento daquelas que não têm relação de parentesco com o réu, porquanto isentas. Assim já decidiram os nossos tribunais:

ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. (...). Materialidade e autoria que restaram indúvidas, especialmente pelas declarações da vítima confirmando a narrativa da denúncia, e o reconhecimento feito em sede policial, no dia seguinte ao roubo. Tese defensiva de negativa de autoria que não encontra respaldo na prova acusatória produzida, no que pese constituir-se esta, basicamente, do depoimento da vítima, sendo certo que as testemunhas de defesa são parentes do réu, e foram ouvidas como informantes, pelo que suas declarações devem ser apreciadas com reservas. (...). (TJ-RJ, APELAÇÃO 0012988-20.2006.8.19.0202 - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - Des(a). KÁTIA MARIA AMARAL JANGUTTA - Julgamento: 31/07/2007)

Corrupção ativa – Oferecimento de dinheiro a policiais para que o réu não seja levado à delegacia - Apreensão de dinheiro e escritos que seriam relacionados com o tráfico - Palavras dos policiais seguras e coerentes - Testemunhas de defesa que são parentes do acusado e cujas palavras devem ser recebidas com reservas – Prova segura - Condenação mantida - Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0390203-86.2010.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José dos Campos - 1ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/04/2012; Data de Registro: 02/05/2012)

PROVA - Testemunhos conflitantes - Prevalência daqueles oferecidos por pessoas estranhas aos partícipes da cena criminosa - Condenação mantida.126 - No conflito de versões oferecidas por pessoas desinteressadas quanto à sorte da demanda, estranhas aos envolvidos na infração e por pessoas sentimental e afetivamente ligadas a um dos personagens, claro que as declarações das primeiras se haverá de conferir credibilidade maior. RJDTACRIM VOLUME 2 ABRIL/JUNHO 1989 PÁGINA: 138 RELATOR:- CANGUÇU DE ALMEID

O acusado Jonathan negou a prática do delito, alegando ser usuário por mais de dez anos e que a droga era para consumo próprio. Disse que estava chegando em casa do trabalho, e tinha acabado de adquirir a droga para consumo, sendo que ao chegar no portão foi abordado pelos policiais, os quais alegaram que o réu estaria traficando para terceiro, tendo negado os fatos. Declarou que ficou na viatura enquanto os policiais entraram na casa. Depois de muita insistência sobre o traficante, sempre com negativa do depoente, os policiais requisitaram sua carteira, tendo informado que estava na casa. Relativo ao dinheiro, confirma a existência sendo proveniente de seu trabalho como vidraceiro informal. Por fim, relativo aos depósitos foram efetuados para aquisição de um carro, negociado pela internet e o qual iria buscar.

No entanto, a versão pueril do réu em juízo, restou isolada no conjunto probatório.

Há que se analisar que as declarações do réu são contrárias ao seu depoimento na Delegacia de Polícia (fls. 11), onde confirmou sua função no tráfico, o que, aliado aos depoimentos das demais testemunhas, torna carente de credibilidade sua negativa

de autoria.

Desta forma, a quantidade de droga, a forma de acondicionamento, os objetos e/ou o valor em dinheiro de origem não elucidada permitem a segura conclusão de que o entorpecente apreendido era destinado ao tráfico, razão pela qual é impossível, ainda, a desclassificação para o consumo pessoal (artigo 28 da Lei 11.343/06). Nesse sentido, o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: Tráfico ilícito de drogas. Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Depoimentos dos policiais civis coesos e harmônicos - Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório. Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Desclassificação do crime para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06. Incabível. A quantidade de drogas apreendidas, bem como a forma que estavam embaladas, prontas para serem entregues a terceiros, e, também, o sugestivo contexto fático que ocorreu a apreensão dos narcóticos, são suficientes para caracterizar o delito de tráfico ilícito de drogas - A condição de usuário não afasta, por si só, a possibilidade de condenação pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 - Redução da pena conforme dispõe o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06. Inadequada. A quantidade, variedade e natureza dos entorpecentes apreendidos representam perigo maior, atingindo incontáveis usuários, além de apresentarem alto risco à saúde pública com a colocação de tamanha quantidade de entorpecentes na rua - Ademais, as circunstâncias do caso concreto revelam a dedicação habitual do apelante à prática do crime de tráfico ilícito de drogas, não se tratando de mero traficante eventual, que, por descuido, envolveu-se com a traficância momentaneamente - (...) - Pena e regime mantidos Recurso desprovido. (Apelação Criminal nº 0002456-25.2017.8.26.0616, da 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: FREITAS FILHO, Data: 29 de janeiro de 2020)

TÓXICO - Tráfico - Desclassificação para uso próprio - Inadmissibilidade - Presença de indícios tipificadores do delito - Apreensão de grande quantidade de entorpecente - Excessivo poder de compra que não se adequa à condição simples do réu - Aplicação dos artigos 12 e 37 da lei 6368/76 - Recurso não provido. (Relator: Gentil Leite - Apelação Criminal n. 161.748-3 - Campinas - 01.09.94)

TÓXICO - Tráfico - Desclassificação para uso próprio - Inadmissibilidade - Ré surpreendida na posse expressiva quantidade de maconha e uma porção de cocaína - Quantidade e natureza da droga que evidencia o objetivo de mercancia - Recurso não provido. (Relator: Segurado Braz - Apelação Criminal n. 161.094-3 - São José do Rio Preto - 16.05.94)

Ainda, em que pesem os depoimentos dos policiais acerca do intenso envolvimento do réu com o tráfico de drogas, as certidões de fls. 26/27, indicam sua primariedade. No mais, o relatório de fls. 244/265, indica a ocorrência de conversas isoladas com apenas duas pessoas, em atos que aparentam traficância, não restando minimamente comprovado que integre a organização crimínosa gerenciada pela pessoa de Becan.

Por fim, nada a prover acerca da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, considerando que o réu foi preso em frente a sua residência.

Pelas provas colhidas nos autos, a condenação do acusado é medida de rigor.

Passo a dosar as penas.

Nos termos do artigo 59 do Código Penal, e do art. 42, da Lei 11.343/06, fixo a pena base no mínimo legal.

Com efeito, segundo Damásio:

“O novo sistema penal prevê duas fases na aplicação da pena. Num primeiro momento, com fundamento no princípio da pena retributiva, fixa sua qualidade e quantidade, elaborando um juízo sobre o passado (juízo de culpabilidade), atendendo à gravidade

objetiva do delito, antecedentes e personalidade do agente, sua conduta social anterior, motivos determinantes do fato e suas conseqüências." (Damásio Evangelista de Jesus, "Direito Penal", Parte Geral, 1 volume, 19ª Edição, Saraiva, 1995, p. 509)

Assim sendo, fixo a pena de cinco anos de reclusão e quinhentos dias multa, para o delito de tráfico de entorpecentes.

Na segunda fase, é impossível a consideração de qualquer circunstância atenuante, tendo em vista que a pena base foi fixada no mínimo. A questão foi abordada na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que lança uma pá de cal sobre a matéria: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Tendo em vista que o réu é primário, não ostenta antecedentes, e não ficou comprovado que se dedique às atividades criminosas e/ou que integre organização criminosa, nos termos do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, diminuo a pena de 2/3 (dois terços), totalizando em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Tema 1139, do STJ: É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06. (REsp 1977027/PR e REsp 1977180/PR)

Na ausência de outras circunstâncias ou causas modificadoras, torno a pena definitiva.

O dia-multa é fixado no piso.

O regime prisional deverá ser o aberto, nos termos do art. 33, §2º, letra "c" do CP.

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao providenciar o cancelamento de sua Súmula nº 512, assentou que o tráfico de entorpecente, em sua forma privilegiada, não tem natureza hedionda.

Nessa linha, consta o julgamento do HC 118.533 do Supremo Tribunal Federal, o qual decidiu pelo afastamento da hediondez do delito de tráfico privilegiado (artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADO POR TRÁFICO PRIVILEGIADO E POR TRÁFICO PREVISTO NO CAPUT DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA AFASTADA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar, em 23/6/2016, o HC 118.533/MS, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, passou a adotar o entendimento de que "o crime de tráfico privilegiado de drogas não tem natureza hedionda". Posteriormente, a Quinta e a Sexta Turmas do STJ, revendo posição anteriormente adotada, passaram a acompanhar o julgado do STF. Desse modo, a execução penal deve tratar o crime praticado pelo paciente como crime comum, e não como crime de natureza hedionda, para fins de cálculo de possíveis benefícios. Precedentes. 2. Está consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento no "sentido de afastar a reincidência específica em relação ao tráfico privilegiado e o tráfico previsto no caput do art. 33 da Lei de Drogas" (HC n. 471.013/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe de 16/10/2018). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 547.502/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

Ainda, a Resolução nº 5 do Senado, suspendeu a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", inserida no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, consagrando o princípio constitucional da individualização da pena. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO

CONHECIMENTO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº.11.343/06. FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO APLICADA. PEQUENA QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. REGIME PRISIONAL FECHADO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. PRIMARIEDADE E MONTANTE DA PENA QUE ENSEJAM O REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 44, DO CP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. - O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 27/07/2012, ao julgar o HC n. 111.840/ES, por maioria, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 11.464/2007, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados. - Ademais, quanto à hediondez do crime de tráfico privilegiado, deve-se acompanhar a decisão do plenário do STF, no exame do HC n. 118.533/MS, julgado em 23/06/2016, de Rel. da Ministra Cármen Lúcia, na qual se assentou que o crime de tráfico privilegiado de drogas não tem natureza hedionda. - Para a imposição de regime prisional mais gravoso do que a pena comporta, é necessária fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos. Inteligência das Súmulas n. 440/STJ e 718 e 719 do STF. - Ora, tendo em vista o montante de pena aplicada, no caso, e considerando que as circunstâncias fáticas concretas não desbordam do ordinário do tipo - apreensão de apenas 1 porção de cocaína, pesando 2 g, e 7 porções de crack pesando 3 g (fl. 27) - cabível o regime inicialmente aberto de cumprimento da pena, conforme art. 33, § 2º, alínea 'c', do Código Penal, c/c art. 42, da Lei n. 11.343/2006. - Do mesmo modo, no que tange à possibilidade de substituição da pena, o Supremo Tribunal Federal, em 1º/09/2010, no julgamento do HC n. 97.256/RS, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do § 4º, do art. 33, e do art. 44, ambos da Lei de Drogas, na parte relativa à proibição da conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos aos condenados por tráfico de entorpecentes. - No caso, estabelecida a pena-base no mínimo legal e considerando a primariedade do paciente e a quantidade mínima das drogas apreendidas, também faz jus o acusado à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, do CP. - Habeas corpus não conhecido. - Ordem concedida, de ofício, para readequar o regime prisional inicial do paciente para a modalidade aberta e substituir a pena corporal por medidas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juiz singular. (HC 459.796/SP, Rel. Ministro REYNALDO OARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 08/04/2019)

Desse modo, cabe ao Julgador verificar a possibilidade de aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 e seguintes do Código Penal.

O réu poderá apelar em liberdade, por estarem ausentes os motivos ensejadores da custódia cautelar.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu JONATHAN SAGRILO, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis), dias-multa, fixado no piso, como incurso no artigo 33, §4º, da Lei nº. 11.343/2006, bem como para condená-lo no pagamento das custas processuais que fixo em 100 UFESPs, nos termos da Lei Estadual nº 11.608/03.

Nos termos dos artigos 43 e seguintes, do Código Penal, em especial os incisos I e IV, do art. 43, converto a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direito, na forma de prestação de serviços à comunidade, por igual período ao da pena privativa de liberdade, a ser definida pelo Juízo das Execuções, e em prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo, em favor de entidade filantrópica do Município.

Ainda, nos termos do que dispõe o artigo 63 da Lei 11.343/2006 determino a perda dos bens e valores apreendidos, em favor da União, devendo se proceder consoante os parágrafos do mencionado artigo após o trânsito em julgado da presente sentença.

Por fim, indefiro o pedido de assistência judiciária requerido pelo acusado, o qual é representado por defensor constituído, revelando, assim, possuir meios para enfrentar os custos do processo, acaso desfavorável a ação penal contra ele instaurada. Não fez, de outra parte, comprovação alguma da alegada necessidade, justificando a benesse.

Ilhabela, 16 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA